

刑法

No96

共通問題 H28-9

(配点: 2)

月 日

月 日

正当防衛及び緊急避難に関する次の1から5までの各記述を判例の立場に従って検討した場合、正しいものはどれか。

1. 国家的法益を防衛するための正当防衛が成立する余地はない。
2. 相手方から急迫不正の侵害を受け、第三者の所有物を用いて相手方に反撃し、同所有物を損壊した場合において、その行為が器物損壊罪の構成要件に該当するとき、その行為につき緊急避難が成立する余地はない。
3. 相手方から急迫不正の侵害を受け、これに逆上して相手方に反撃を加えた場合、正当防衛が成立する余地はない。
4. 相手方から急迫不正の侵害を受け、相手方に反撃を加えた場合、その侵害が相手方の過失に基づくものであれば、正当防衛が成立する余地はない。
5. 正当防衛が成立する行為に対しては、正当防衛が成立する余地はない。

1 誤っている

最判昭24.8.18。判例は、「公益ないし国家的法益の防衛が、正当防衛として認められ得るか否かについては、……公共の福祉を最高の指導原理とする新憲法の理念から言っても、公共の福祉をも含めてすべての法益は防衛せらるべきであるとする刑法の理念から言っても、国家的、国民的、公共的法益についても正当防衛の許さるべき場合が存することを認むべきである。」としており、36条1項にいう「権利」には、国家的法益も含まれることを認めている。

2 誤っている

261条、37条1項本文。防衛者が反撃行為の際に第三者の物を損壊（261条）した場合、反撃行為自体は、相手方との関係においては、急迫不正の侵害に対する正当防衛となされたものといえるが、その反撃行為の手段として正なる第三者の法益が侵害されているのであるから、反撃行為者と第三者とは正対正の関係にあり、損壊行為には緊急避難（37条1項本文）の成立する余地がある。

3 誤っている

最判昭50.11.28（百選I24事件）。判例は、「防衛に名を借りて侵害者に対し積極的に攻撃を加える行為は、防衛の意思を欠く結果、正当防衛のための行為と認めることはできないが、防衛の意思と攻撃の意思とが併存している場合の行為は、防衛の意思を欠くものではないので、これを正当防衛のための行為と評価することができる」としている。そのため、単に急迫不正の侵害に逆上して反撃を行った場合であっても、防衛の意思が併存している限り、防衛の意思が肯定されることになる。

4 誤っている

36条1項。36条1項にいう急迫不正の「侵害」とは、法益に対する実害又はその危険を生じさせる行為をいい、故意行為であるか過失行為であるかを問わない。よって、侵害が相手方の過失に基づくものであっても、正当防衛が成立する余地がある。

5 正しい

36条1項。「不正」とは、全体としての法秩序に反すること、すなわち違法であることをいう。そのため、侵害行為に正当防衛が成立する場合、侵害行為の違法性が阻却されるため、侵害行為は違法ではなく「不正」とはいえない。よって、正当防衛が成立する行為に対しては、正当防衛は成立する余地はない。